

1501743-77.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... estar trabalhando apenas como olheiro do tráfico, além de não ter feito prova neste sentido, e tão pouco trouxe essa versão desde o início, como seria o correto e normal se fosse verídica, tal tese não lhe favorece já que ele próprio afirmou que seria seu terceiro dia no tráfico, de modo que não se pode dizer que apenas colaborava para o tráfico, como informante, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501743-77.2021.8.26.0537 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501743-77.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240449/2021 - DISE-DEL.SEC.DIADEMA, 20027350 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 81/21/301 - DISE-DEL.SEC.DIADEMA, 2240449 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Victor Hugo Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

VISTOS.

VICTOR HUGO SANTOS, qualificado às fls. 06/07 está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 15h40, na Passagem Dezenove de Março, altura do nº 10, bairro do Canhema, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 9 embalagens plásticas contendo oito gramas da droga cocaína e 23 embalagens plásticas contendo cento e um gramas da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 23/24 e laudo de constatação provisória de fls. 28/30, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl. 55/59), a, denúncia foi recebida em 19/10/2021 (fl.121), sem proposta de transação penal, e seguiu-se com a notificação e citação do réu, quem ofertou defesa inicial as fls. 117/118, por Advogado constituído.

Em audiência una foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal diante da quantidade e variedade de drogas altamente nocivas como o crack e cocaína bem como pelos maus antecedentes criminais do réu, e por isso, sem possibilidade de redução da pena nem sua substituição, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, sem direito de apelo em liberdade, com o perdimento do numerário apreendido.

Já o d. Advogado pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena e fixando-se regime mais brando, com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, e direito de apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem no auto de exibição e apreensão de fls.23/24, laudos de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha e cocaína (respectivamente às fls. 28/30 e 97/99) além da apreensão de numerário proveniente da mercancia ilícita (R\$41,00 - fl.25 e 94).

A autoria é inconteste conforme prova que sigo analisando.

Os policiais civis afirmaram em solo pré-processual (fls.02/03) que diligenciavam com uma viatura descaracterizada pelo conhecido local de traficância de drogas, pararam a viatura com visão ao local onde costuma ficar o "Vapor", pessoa responsável venda da droga, e puderam visualizar um individuo pardo, de camiseta de cor azul e bermuda branca, com uma sacola plástica na mão. Resolveram aborda-lo. Identificado como sendo VICTOR HUGO SANTORES, em busca pessoal foram localizados R\$ 41,00 em notas de pequeno valor, e na sacola que trazia em mãos haviam vários invólucros de substancias assemelhadas a cocaína e maconha. Questionado, assumiu que estava vendendo as drogas naquele local e que receberia para isso o valor de R\$ 50,00 mais uma unidade de maconha, sendo exarada voz de prisão ao mesmo pelo crime de tráfico de drogas.

Em juízo o policial Adriano Ponte reiterou que o local é um ponto conhecido por vender drogas. Pararam próximo ao local onde as drogas são comercializadas. Visualizaram o réu parado. Abordado, com ele estava o dinheiro e em sua mão uma sacola contendo as drogas, tendo confessado o tráfico e que os quarenta e um reais eram da venda das drogas. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu na biqueira.

Neste sentido foi o depoimento do policial William Carrieri alegou terem feito uma campana de cerca de quinze minutos quando visualizaram o réu com uma sacola na mão. Ele saiu e depois entrou numa viela. Foi abordado e na sacola localizaram cocaína e maconha e uns quarenta reais. Reconhece o réu. O local é um ponto de tráfico e por

isso foram diligenciar, e foi a primeira vez que o viram lá. Não falou com o réu sobre as drogas e a posse por parte do réu.

O réu, extrajudicialmente (fl.04), respondeu que está desempregado a aproximadamente um ano e vem se virando para sustentar a sua família, pois tem uma filha pequena de apenas 3 anos. Diante da falta de oportunidades, há três dias aceitou a oferta de um indivíduo desconhecido de vender drogas. Declarou que fica naquele local em horários variáveis. Na data de ontem ficou das 9 as 19 horas e hoje chegou as 14:00 e ficaria até as 22:00 horas, e ao final do seu turno recebe a quantia de R\$ 50,00 mais um invólucro de maconha, substância da qual é usuário. Declarou que vendia a unidade do invólucro de cocaína por R\$ 10,00 e a unidade do invólucro de maconha por R\$ 5,00 ou R\$ 10,00 dependendo do tamanho do invólucro. Declarou que estava na biqueira quando os policiais desceram de um carro normal, o abordaram com as drogas, avisaram que estava preso, e o trouxeram a delegacia.

Sob o crivo do contraditório o acusado alegou que estava na rua Aires da Cunha, n. 154, longe da Passagem 19 de março. Estava envolvido com o tráfico sim, mas como olheiro. E mostrou para os policiais onde estavam as drogas. Entrou nessa dois dias antes de ser preso para poder colocar comida em casa para seus filhos e pagar o aluguel e não ir morar na rua. Estava trabalhando para o tráfico, mas como olheiro. O traficante correu e quando foi abordado, perguntaram onde estava o traficante, já que disse que estava como olheiro, e então apontou onde estavam escondidas as drogas, atrás de um telhado de um galinheiro, ao lado do escadão, atrás do telhado. Logo, o interrogatório com a confissão extrajudicial e a informal prestada pelo réu não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais e a apreensão de numerário proveniente da mercancia ilícita, sem prova contrária, até porque, embora nesta audiência ele alegue estar trabalhando apenas como olheiro do tráfico, além de não ter feito prova neste sentido, e tão pouco trouxe essa versão desde o início, como seria o correto e normal se fosse verídica, tal tese não lhe favorece já que ele próprio afirmou que seria seu terceiro dia no tráfico, de modo que não se pode dizer que apenas colaborava para o tráfico, como informante, de forma esporádica, informal, sem qualquer tipo de envolvimento ou relação com a prática de outra conduta ligada à traficância, até porque sabia e indicou onde estavam as drogas, o preço de cada turno de trabalho, enfim, contexto probatório indica que ele era o responsável pelas drogas e pelas vendas das mesmas, ou seja, ele era o vapor, até porque só hoje alegou que quem seria o verdadeiro traficante correu, mas os policiais não viram ninguém além do réu.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. E na presente hipótese, ainda, houve a confissão do réu, além do que a defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza ou desemprego, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Também não há que se falar em estado de necessidade,

pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 25), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, assim como a quantidade de narcótico apreendido (32 invólucros no total) que não reputo excessivo, mas considerando os maus antecedentes criminais do acusado, condenado definitivamente por crime análogo (fl. 33/35, nas comarcas da Capital e de Conchas), e consoante atual entendimento exarado no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal: "No sistema normativo brasileiro, o conceito de reincidência não se confunde com maus antecedentes. Portanto, não é possível aplicar o mesmo prazo quinquenal para os dois institutos. Cinco anos valem para apagar a reincidência, não os maus antecedentes. Assim, entendo que não é possível alargar a interpretação da reincidência de modo a incluir os maus antecedentes, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo, qual seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a também fundamentar o presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja tecnicamente primário (fls.71/78), mas considerando a natureza da droga cocaína, sua nocividade, alto poder viciante e degradante do ser humano, além da quantia em dinheiro apreendida, proveniente de efetivas vendas de narcóticos realizadas, de modo que disseminado o vício entre os usuários, a indicar maior envolvimento com a mercancia, tanto que o réu confessou estar trabalhando há dias no local, opto pelo percentual mínimo de 1/3 a reduzir a reprimenda para 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Fixo o regime prisional semiaberto por conta das circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP, ou seja, maus antecedentes do réu, por crime análogo inclusive. Segundo entendimento do STJ já firmado, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Assim, pode ser fixado regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar tais circunstâncias, no caso em tela a cocaína e os maus antecedentes específicos do acusado a justificar a escolha pelo regime intermediário. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal, porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal" (STJ, HC 117812/MG).

Incabível a benesse do art. 44 do CP ao réu diante da reiteração criminosa a demonstrar não ser socialmente recomendável, até porque a conduta deve ser considerada grave, sendo insuficiente e ineficaz à sua reprovação e à ressocialização do agente diante da elevada culpabilidade, sob pena de se potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social dado o elevado número de ocorrências de tal natureza, conferindo desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o tráfico, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem da prática de delitos que tais seu verdadeiro meio de vida como o réu no caso, já condenado por crime análogo.

Some-se a isso o fato de que : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu, ora condenado a regime que o manterá preso para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há pouco mais de três meses, e sem direito sequer à progressão de regime, considerando a prisão do réu por menos de quatro meses.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à

verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra VICTOR HUGO SANTORES, qualificado às fls. 04 e 06/07, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 UFESPS ante a constituição de Advogado particular, sem declaração nem prova de hipossuficiência até a presente data.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 94), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias e em 60 dias as custas, sob as pena da lei.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se

Diadema, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA